

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제4절 증거조사의 개시와 실시>

I. 증거조사의 개시

1. 증거신청

(1) 증거신청의 의의

- 증거신청이란 당사자가 자기의 주장을 뒷받침하기 위하여 법원에 대하여 특정한 증거방법을 조사하여 줄 것을 요구하는 소송행위를 말한다. 변론주의가 적용되는 민사소송에서 증거조사는 원칙적으로 당사자의 신청에 의하여 개시된다.

(2) 증거신청의 절차

- 증거신청은 증명할 사실을 구체적으로 표시하여야 하며, 증거방법을 특정하여야 한다. 서증은 문서를 제출하거나 제시하는 방식, 증인은 성명과 주소를 기재하여 신청하는 방식 등을 취한다. 신청 시기는 변론준비기일이나 변론기일 등 적절한 시기에 행해져야 하며, 법원이 정한 기간 내에 제출하지 않으면 실기한 공격방어방법으로 각하될 수 있다.

(3) 증거신청의 철회

- 당사자는 신청한 증거를 법원이 채택하기 전이나 채택한 후라도 증거조사가 개시되기 전까지는 자유롭게 철회할 수 있다. 그러나 일단 증거조사가 시작되어 그 결과가 법관의 심증 형성에 영향을 미친 후에는 상대방의 동의 없이 함부로 철회할 수 없다는 것이 통설의 입장이다.

2. 증거신청에 대한 채부결정

(1) 증거신청의 채부결정[민소법 제290조]

- 법원은 당사자가 신청한 증거에 대하여 채택 여부를 결정할 권한을 가진다. 민사소송법 제290조 본문에 따라 법원은 당사자가 신청한 증거가 불필요하다고 인정되는 경우에는 이를 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 사실인정에 결정적인 영향을 미치는 증거를 정당한 이유 없이 배척하는 것은 채증법칙 위반이 될 수 있다.

(2) 유일한 증거

- 당사자의 주장 사실을 증명할 수 있는 유일한 증거방법인 경우, 법원은 특별한 사정이 없는 한 이를 반드시 채택하여 조사하여야 한다. 이는 당사자의 증명권 보장과 실체적 진실 발견을 위한 예외적 강제 사항이다.

(3) 증거결정

- 법원이 증거신청을 받아들이는 것을 증거채택결정, 거부하는 것을 증거각하결정이라 한다. 증거결정은 판결 전의 소송절차에 관한 결정이므로 독립하여 상소할 수 없으며, 종국판결에 대한 상소로 다투어야 한다.

3. 직권증거조사[민소법 제292조]

- 민사소송법 제292조는 법원은 당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 현대 소송에서 실질적 공평을 기하기 위한 변론주의의 보완책으로 활용된다.

II. 증거조사의 실시

1. 의의

- 증거조사의 실시란 채택된 증거방법을 통해 증거자료를 획득하는 구체적인 절차를 의미한다. 법원은 증거조사를 통해 사실인정의 기초가 되는 확신을 얻게 된다.

2. 증인신문

(1) 의의

- 증인신문이란 법원이 소송당사자 이외의 제3자로부터 그가 과거에 경험한 사실을 진술하게 하여 증거자료를 얻는 증거조사 방법이다.

(2) 증인능력

- 누구든지 증인이 될 수 있는 법률적 자격을 가진다. 유아나 정신지체인이라도 자기의 체험을 진술할 수 있는 지적 능력이 있다면 증인능력이 인정된다.

(3) 증인의무

- 모든 국민은 증인으로서 출석의무, 선서의무, 진술의무를 진다. 정당한 사유 없이 출석하지 않거나 진술을 거부할 경우 과태료나 감치 등의 제재를 받을 수 있다.

(4) 증인조사방식

- 원칙적으로 구술 신문 방식에 의하며, 증인이 법정에서 출석하여 신문에 응해야 한다. 다만, 예외적으로 서면에 의한 답변으로 갈음하는 것도 가능하다.

(5) 증인신문방법[민소법 제327조]

- 신문은 주신문, 반대신문, 재주신문 순서로 진행된다. 증인을 신청한 당사자가 먼저 주신문을 하고, 상대방이 반대신문을 통해 진술의 탄핵 및 유리한 사실을 이끌어낸다.

(6) 유도신문

- 주신문에서는 원칙적으로 유도신문이 금지되나, 반대신문에서는 증인의 기억을 환기시키거나 진술의 모순을 지적하기 위해 널리 허용된다.

3. 감정

(1) 의의

- 감정이란 법관의 판단 능력을 보충하기 위하여 특별한 학식이나 경험을 가진 자로부터 그 전문적 지식을 활용한 판단을 보고받는 증거조사 방법이다.

(2) 감정결과의 증거력

- 감정결과는 법원을 구속하지 않는 자유심증주의의 대상이다. 그러나 감정인의 판단이 논리적이고 객관적이라면 법원이 이를 합리적 이유 없이 배척하기는 어렵다.

(3) 감정결과의 채택 여부

- 법원은 감정결과가 미진하다고 판단될 경우 재감정을 명하거나 추가 설명을 요구할 수 있다.

4. 당사자 신문[민소법 제367조, 제372조]

(1) 의의

- 당사자 신문이란 법원이 당사자 본인을 신문하여 사실인정의 자료를 얻는 증거조사 방법이다. 법정대리인도 이에 준하여 취급된다.

(2) 보충성의 폐지

- 과거에는 다른 증거방법이 없는 경우에만 예외적으로 허용되었으나, 현행법상 보충성이 폐지되어 다른 증거가 있더라도 언제든지 신청할 수 있다.

(3) 당사자신문의 절차

- 증인신문 절차를 준용하며, 선서 후 신문이 이루어진다. 다만, 당사자는 증인과 달리 과태료 외에 진술 거부 시 주장 사실의 자백 간주라는 불이익을 받을 수 있다.

(4) 당사자신문의 효과

- 신문 결과 얻어진 자료는 독립적인 증거원인이 되며 법관의 심증 형성 자료가 된다.

(5) 관련 문제

- 공동소송인 중 1인에 대한 신문 결과가 다른 공동소송인에게 미치는 영향 등은 소송 형태에 따라 개별적으로 판단된다.

5. 서증

(1) 서설

- 서증이란 문서를 읽어 그 기재 내용을 증거자료로 삼는 증거조사 방법이다. 민사재판에서 가장 비중이 큰 증거방법이다.

(2) 문서의 증거능력

- 민사소송에서는 원칙적으로 문서의 증거능력에 제한이 없다. 사적인 서신이나 일기 등도 증거로 사용될 수 있다.

(3) 문서의 증거력

- 문서가 작성자의 의사에 따라 진정하게 성립되었는가가 핵심이다. 특히, 처분문서(계약서 등)는 진정성립이 인정되면 그 기재 내용대로 법률행위의 존재를 인정해야 하는 강력한 증거력을 가진다.

(4) 서증의 신청절차[민소법 제343조]

- 문서를 직접 제출하거나, 상대방 또는 제3자가 소지한 경우 문서제출명령을 신청하는 방식으로 행해진다.

6. 검증

(1) 의의

- 검증이란 법관이 자신의 오관(눈, 코, 귀 등)의 작용에 의해 사물의 성상이나 현상을 직접 관찰하여 증거자료를 얻는 조사 방법이다.

(2) 검증의 대상

- 동영상 파일, 부동산의 현황, 물건의 파손 부위, 인체의 상흔, 소리나 냄새 등 오관으로 지각할 수 있는 모든 유체물이 대상이 된다.

7. 증거보전

(1) 증거보전의 의의

- 미리 증거조사를 해 두지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우, 본안 소송의 개시 전이나 소송 중에 미리 증거조사를 하는 제도가 있다.

(2) 증거보전의 요건

- 증거를 미리 조사하지 않으면 증거방법의 멸실, 훼손 또는 변경 등의 우려가 있어야 한다. 증인의 해외 출국이나 중병, 물건의 부패 가능성 등이 예시가 된다.

(3) 증거보전의 절차

- 당사자의 신청에 의하며, 원칙적으로 해당 증거를 소지한 사람의 거소지나 물건 소재지 관할 법원에 신청한다.

(4) 증거보전의 효력

- 보전된 증거조사 결과는 본안 소송에서 별도의 신청 없이도 증거자료로 사용될 수 있다. 다만, 당사자가 이를 변론에서 원용하여야 한다.

Ⅲ. 결론

- 증거조사의 개시와 실시는 민사재판에서 실체적 진실을 규명하기 위한 핵심적인 과정이다. 증거신청과 채부결정이라는 입구 단계에서부터 증인, 서증, 감정 등 다양한 증거방법이 개별적 절차에 따라 실시되는 과정 전반은 법관의 합리적 심증 형성을 목적으로 한다. 특히, 서증 중심의 재판 실무 속에서도 증인신문이나 당사자신문의 적절한 운영은 사건의 이면에 숨겨진 진실을 파악하는 데 필수적이다. 또한, 증거보전 제도는 시간적 경과에 따른 증거인멸의 위험을 방지함으로써 당사자의 증명권을 실질적으로 보장한다. 법원은 각 증거방법의 특성을 고려하여 절차의 공정성을 유지하고, 당사자는 적절한 시기에 효과적인 증거방법을 제시함으로써 자신의 권리를 방어해야 한다. 이러한 유기적 협력을 통해 민사소송법이 지향하는 적정·신속·경제의 이념이 구현될 수 있다.